

1500370-76.2021.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO BAREA BORGES

Comarca: Quatá

Foro: Foro de Quatá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... de domicílio. Dessarte, considerando flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do agravante de guardar a droga em sua residência, bem como considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes (49,9g de crack), caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Quatá

Foro de Quatá

Vara Única

Av Rui Barbosa, 844, Quata - SP - cep 19780-000

1500370-76.2021.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500370-76.2021.8.26.0580

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD EDUARDO MATIAS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO BAREA BORGES

Vistos.

RICHARD EDUARDO MATIAS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado por ter cometido, em tese, o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 12 de outubro de 2021, por volta da 1h, na Vicinal SPV 052 - km. 02, 1 - Área Rural, nesta cidade e comarca de Quatá/SP, trazia consigo 241 (duzentos e quarenta e um) invólucros de cocaína/crack e 19 (dezenove) porções de maconha, com fins de tráfico (fls. 01/03). Homologada, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 74/80), cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido (fls. 87/88).

A Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus com Pedido Liminar para expedição de alvará de soltura em favor do paciente (fls. 103/110), sendo a liminar e o Habeas Corpus indeferidos, mantendo o acusado preso (fls. 111/116).

O réu foi notificado e citado (fl. 146), tendo apresentado defesa preliminar de fls. 154/173.

Mantida a prisão preventiva e recebida a denúncia em 13 de dezembro de 2021, tendo sido designada, na mesma oportunidade, audiência de instrução e julgamento (fls. 182/184).

Na audiência de instrução (fls. 228/230), foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma informante e, ao final, o réu foi interrogado.

Após manifestação da defesa do réu (fl. 231), foi homologada a desistência da oitiva da testemunha arrolada pela defesa faltante, encerrando-se a instrução (fl. 232).

Em alegações finais (fls. 246/253), o representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria dos delitos restaram efetivamente comprovadas, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria, pugnou que a pena-base fosse fixada em patamar substancialmente acima do mínimo legal, ante a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas. Opinou pela fixação do regime prisional fechado.

Decisão mantendo a prisão preventiva do réu (fl. 258).

A defesa, por seu turno, às fls. 260/276, em sede de preliminar, requereu o reconhecimento da ilicitude da prova, sob o argumento de que houve violação de domicílio, com a consequente absolvição do réu. No mérito, além da alegar a fragilidade probatória, sustentou que o réu, ao tempo dos fatos, era incapaz, devido ao fato de ser usuário de drogas (dependente químico), sem a capacidade de entendimento e determinação e, por consequência, ausente o dolo, pugnando pela absolvição. Destacou, ainda, que nenhuma prova de traficância foi produzida, de forma que, no máximo, o réu poderia ser enquadrado como usuário, pleiteando a desclassificação para o art. 28 da lei de drogas. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa e com a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, com a fixação do regime aberto, convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de que seja reconhecido o direito do acusado em recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público deste Estado imputa ao acusado a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de nulidade, sob o argumento de que foi violado o domicílio do réu, por não ter sido autorizada a entrada na residência para a realização de diligências pelos policiais militares.

Depreende-se da prova coligida nos autos que, após ser encontrado com as substâncias entorpecentes (situação que será melhor pormenorizada adiante), o acusado declinou seu logradouro aos agentes, pois ele não estava em posse de seus documentos pessoais, bem como informou aos policiais que no interior de seu quarto havia mais substâncias entorpecentes, confessando, informalmente, devido à preocupação de manter as drogas na casa de sua mãe após sua prisão em flagrante. A despeito dos argumentos apresentados pela defesa, a diligência foi realizada em estrita observância aos ditames constitucionais e legais, eis que, tratando-se, o crime de tráfico de drogas, de delito classificado como permanente, ou seja, cuja consumação se protraí no tempo, entende-se que o agente permanece em flagrante enquanto não cessar a permanência, de modo que, estando o autuado em situação de flagrância, como descrito pelas testemunhas (policiais militares), possível a entrada na residência, ainda que sem mandado judicial, situação excepcionada pela própria Constituição Federal (art. 5º, XI).

Há precedentes convergentes do STF e o STJ neste mesmo sentido, senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1.

Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 207793 SP 0062962-38.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/01/2022).

Destaquei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS

ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, após "realização de campana, os Policiais Civis localizaram em sua residência pequenas porções fracionadas de crack cujo peso líquido atingiu 35,1 gramas, bem como 23 porções da mesma substância cujo peso líquido alcançou 24,3 gramas", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do agravante de guardar a droga em sua residência, bem como considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes (49,9g de crack), caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, a despeito da devida autorização dos residentes. III - De mais a mais, está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o agravante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 153475 SP 2021/0287369-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021). Destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Preliminar de nulidade - Violação ao domicílio - Inadmissibilidade - Flagrante ilícito - Natureza permanente do crime de tráfico de drogas - Justa e prévia causa demonstrada - Preliminar afastada. Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Absolvição - Inviabilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida - Recurso improvido. Redução da reprimenda - Antecedentes desabonadores justificam a majoração da reprimenda - Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15059559820218260228 SP 1505955-98.2021.8.26.0228, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022). Destaquei.

Ainda que a D. Defesa argumente que a genitora do acusado não franqueou a entrada dos agentes policiais na residência, fundamentando sua defesa pelas declarações da informante em audiência, entendo que os argumentos por ela apresentados, no sentido de que fora obrigada a gravar um suposto vídeo dizendo que autorizava a entrada dos policiais, bem como que assinara um documento na Delegacia de Polícia sem ao menos atentar-se ao conteúdo, não convencem, pois, além de não ser compatível com a gravidade dos fatos (filho sendo acusado de tráfico de drogas), também destoa dos elementos de prova coligidos nos autos.

Assim, considerando que, logo após a autuação em flagrante, o réu indicou a localização exata em que guardava mais substâncias entorpecentes, in casu, a guarda de entorpecentes para o fim de traficância configura crime permanente, permitindo a invasão do domicílio e o flagrante a qualquer tempo. Considerando que os elementos anteriores ao fato justificaram a ação, entendo que não houve abuso por parte dos agentes da polícia durante a execução da medida, inexistindo nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância.

Deste modo, superada a preliminar e não havendo outras nulidades/preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito.

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que os elementos de convicção trazidos aos autos demonstram com clareza a confluência de todas as elementares do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15/18), pelas fotografias (fls. 19/24), laudos periciais químico-toxicológico

de entorpecente (fls. 128/140), bem como pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com o contido no "Auto de Exibição e Apreensão" (fls. 12/13), verifica-se que foram apreendidos no momento da abordagem e após revista pessoal no réu, 15 (quinze) invólucros contendo a substância cocaína, localizados dentro de um maço de cigarro e 11 (onze) porções individuais de maconha, localizadas dentro do bolso do réu.

Após, devido ao fato do réu não estar em posse de documentação pessoal, os policiais militares se dirigiram até sua residência, tendo sido localizadas mais substâncias entorpecentes, consistentes em 08 (oito) porções de maconha, 85 (oitenta e cinco) invólucros contendo cocaína e 141 (cento e quarenta e uma) porções de crack.

Somadas, a apreensão totalizou em 241 (duzentos e quarenta e um) invólucros de cocaína/crack e 19 (dezenove) porções de maconha, todas embaladas em porções individuais e prontas para a comercialização, conforme se verifica das fotografias (fls. 19/24).

No "Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente" (Laudo Pericial nº 334826/2021 - fls. 15/18), exames periciais resultaram "positivo" para "cocaína" com peso líquido de 3,8 gramas (ref. às 15 porções); "maconha" com peso líquido de 11,49 gramas (ref. às 11 porções); "cocaína" com peso líquido de 21,99 gramas (ref. às 85 porções); "maconha" com peso líquido de 7,54 gramas (ref. às 8 porções); e "cocaína (crack)" com peso líquido de 24,74 gramas (ref. aos 141 invólucros).

No "Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo" de fls. 128/140 e restou efetivamente detectada a presença das referidas substâncias.

Por sua vez, a autoria do delito é certa e recai na pessoa do acusado, senão, vejamos.

De início, vale destacar que o acusado fora preso em flagrante (fl. 04), já que, após a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram substâncias que em muito se assemelhavam às drogas popularmente conhecidas como "maconha" e "cocaína", em grande quantidade, tendo sido localizadas, posteriormente, em sua residência, as drogas descritas na inicial acusatória.

As testemunhas ouvidas em juízo, por sua vez, são categóricas em apontar o acusado como autor do delito imputado na denúncia.

A primeira testemunha, o policial militar Luís Rogério Moreno Sanches, afirmou que trabalha na força tática da cidade de Tupã e, em diligência nesta Comarca, observaram que havia vários carros parados na beira da rodovia indicada na denúncia. Apontou que observaram várias pessoas na beira da rodovia e o réu Richard, ao ver a viatura, demonstrou grande nervosismo e o depoente começou a observá-lo e viu que ele dispensou algo no chão e tentou esconder com o pé, sendo que o depoente e os policiais desceram, fizeram a revista e identificaram que o réu tinha dispensado drogas. Apontou que ele não estava portando documentos pessoais e ele falou que estava em casa, sendo que ele passou o endereço e foram na casa, sendo que na viatura o próprio réu já falou que tinha mais droga na casa. Apontou que, na residência do réu, tinha uma sacola plástica, ao lado do documento, com diversas drogas. Apontou que inclusive a mãe do réu autorizou a entrada da polícia e na presença da mãe do réu. Apontou que na sacola tinham mais centenas de porção de crack e dezenas de cocaína. Apontou que as drogas da casa eram idênticas as que haviam localizado na abordagem ao réu e o réu confessou que estava vendendo.

Relatou que a mãe dele mencionou que o réu já tinha tido problema por vender drogas quando era menor. Apontou que a abordagem inicial ao réu foi no acostamento da rodovia. Apontou que não abordaram pessoas na chácara.

A segunda testemunha, o policial militar Anderson Avellaneda Luz, afirmou que trabalha na cidade de Tupã e, em diligência nesta Comarca, observaram que havia uma chácara com várias pessoas e muitos carros parados na rodovia. Apontou que observaram várias pessoas na beira da rodovia e o réu Richard, ao ver a viatura, jogou algo no chão. Apontou que desceram e abordaram o réu e, em abordagem pessoal, localizaram maconha no bolso do réu. Já no chão, viram que o réu tinha jogado no chão um papel com vários papелotes com cocaína. Apontou que ele não estava portando documentos pessoais e ele falou que estava em casa, sendo que ele passou o endereço

e foram na casa, sendo que na viatura o próprio réu já falou que tinha mais droga na casa. Que o réu disse que, como ele ia ser preso, não queria que os entorpecentes permanecessem em sua residência, já que sua mãe morava com ele. Apontou que na residência o acusado indicou o local e os policiais localizaram mais cocaína, semelhante à que foi encontrada com ele, além de maconha e crack. A informante Lucélia Aparecida Mathias, mãe do réu, afirmou que os policiais chegaram no local com Richard preso e, de forma não autorizada, reviraram tudo no local. Apontou que depois fizeram a depoente gravar um vídeo. Apontou que o réu trabalhava na roça. Apontou que assinou o papel do depoimento na delegacia, mas era só para assinar e a depoente não leu, sendo que foi indagada se a polícia tinha sido autorizada e falou que não. Apontou que não tem costumes de assinar papel sem ler, mas estava nervosa. Apontou que o policial gravou um vídeo da depoente, pedindo para depoente falar que autorizou a entrar na residência, mas isso não era verdade. Confirmou que Richard já foi apreendido por tráfico quando era menor de idade.

O réu RICHARD EDUARDO MATIAS DE SOUZA, em seu interrogatório, afirmou que os policiais, antes do dia dos fatos, localizaram o depoente fumando maconha e como o depoente não quis falar onde ficavam as biqueiras da cidade, foi jurado pelos policiais. Três dias depois, no dia dos fatos, o depoente foi na festa no local dos fatos e levou maconha para uso próprio, já que é usuário, sendo que o policial chegou e pediu novamente das biqueiras e o depoente não quis falar, então falou que era para o depoente "abraçar umas drogas que localizaram". Negou que tais drogas eram sua. Apontou que já foi internado na fundação casa por tráfico quando era menor.

Pois bem.

Ao final da instrução criminal, em que pese a tese sustentada pelo nobre Defensor e a negativa da autoria pelo réu, a pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta acolhimento, eis que restou amplamente demonstrada, de forma firme e segura, a responsabilidade do réu pela prática do delito narrado na denúncia, diante das as provas produzidas, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Observa-se que, na fase policial (fl. 08), o acusado confirmou que as substâncias entorpecentes encontradas em sua posse eram de sua propriedade e que as estava comercializando (não apenas para uso próprio), além de ter demonstrado preocupação em manter maior diversidade e quantidade de drogas na residência de sua mãe após a prisão em flagrante.

Em seu interrogatório judicial (fls. 228/230), no entanto, o réu alterou sua versão dos fatos, sustentando ser apenas usuário de droga (maconha) e que os policiais fizeram-no assumir a propriedade das substâncias, introduzidas para incriminá-lo, devido ao fato do acusado não ter auxiliado os agentes na localização de pontos de vendas de drogas na cidade.

Observo que sua versão se mostrou desprovida de o mínimo de elemento probatório.

A análise das provas coligidas nos autos não deixa dúvida que as drogas descritas na denúncia e constantes no auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) sejam efetivamente de propriedade do acusado e que o crime a ele atribuído na denúncia se configurou.

A palavra do acusado se encontra em dissonância com o conjunto probatório angariado nos autos, em especial das testemunhas, policiais militares, que estavam presentes no momento da abordagem e foram harmônicos em relatar o encontro das drogas na residência da ré.

De acordo com os depoimentos, prestados de forma uníssona em ambas as fases da persecução penal, os policiais militares notaram o nervosismo do réu com a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem, além de terem visualizado o acusado dispensar algo ao chão. Em revista pessoal, foram localizadas, no interior do bolso do réu, porções de maconha e, próximo a ele, papелotes contendo cocaína. Pelo fato do acusado não estar em posse de seus documentos pessoais, ele forneceu seu endereço residencial, além de ter, informalmente, confessado aos policiais que no interior de seu quarto havia mais substâncias entorpecentes e que sua mãe desconhecia este fato.

Os policiais se dirigiram ao endereço fornecido e foram recebidas pela genitora do réu, Sra. Lucélia Aparecida Matias, que, além de franquear o ingresso no imóvel, também informou que o acusado já havia sido apreendido, quando adolescente, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Após, diligências na residência do réu, os policiais lograram êxito em encontrar as substâncias indicadas pelo acusado, em maior quantidade e diversidade (cfr. fotográficas às fls. 19/24).

Ressalto que os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e harmônicos entre si, possuem valor probatório semelhante a qualquer outro testemunho, mormente quando não evidenciado – como na hipótese versada nos autos – nenhum elemento de convicção dando conta de má-fé ou abuso de poder.

Ora, nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado.

Além disso, não há por que se desconfiar da palavra dos policiais militares que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, não havendo motivos para que armassem contra a ré, conforme tese defensiva, dissonante de todo conjunto probatório angariado nos autos.

Dar-se crédito àqueles que são detidos em plena e objetiva ação delitosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Quanto à valia dos depoimentos de policiais em juízo:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” (STJ HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28/06/2011).

No mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – DEPOIMENTO DO POLICIAL SEGURO E COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo o policial que participou da prisão do réu apresentado depoimento seguro e coerente com os demais elementos dos autos, no sentido de que o réu trazia os entorpecentes destinados à comercialização, e inexistindo evidência de que aquele tivesse qualquer motivo para incriminá-lo falsamente, impõe-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, “caput” e § 4º, da Lei nº 11.343/06. (TJ-SP 00007090220158260037 SP 0000709-02.2015.8.26.0037, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 26/04/2018, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/05/2018). Destaquei.

Dessa forma, não consigo identificar motivo suficiente que teriam os dois policiais que prestaram depoimento para mentir sobre os fatos, atribuindo falsamente a prática de crime tão grave ao réu. Desacreditar a palavra dos policiais militares em contexto probatório desta envergadura mostra-se extremamente temerário.

Por oportuno, friso que o acusado não apresentou nenhuma reserva em relação aos policiais que depuseram em Juízo e fizeram a apreensão do entorpecente.

A versão apresentada pela informante, genitora do réu, de que não autorizou a entrada dos policiais na residência, de que foi obrigada a gravar um vídeo e que assinou, na Delegacia de Polícia, um papel sem ao menos lê-lo, por estar se sentindo nervosa, é inconsistente e encontra-se completamente dissociada do vasto caderno processual. Ora, por certo que por certo que, se assim o fosse, já teria procurado, logo em seguida, os órgãos responsáveis (MP, advogado ou até mesmo o fórum desta Comarca) para relatar os abusos que teriam sido praticados na delegacia e se retratar da versão dada, o que não ocorreu.

Ressalto que a versão apresentada pelo réu, em juízo, é incapaz de infirmar as provas coligidas, seja por contrariar seu próprio interrogatório policial (ocasião em que ele admitiu a prática delitiva), seja por não descrever situação minimamente capaz de explicar a apreensão de considerável quantidade de drogas no contexto de sua prisão, além da diversidade.

Importante salientar que o tipo penal em questão não exige o especial fim de agir, ou seja, não exige a efetiva prática de atos de mercancia por parte do acusado, bastando que o agente haja com dolo, dirigindo sua conduta à realização de um dos núcleos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que o crime em tela é do tipo misto alternativo.

Assim, restou devidamente demonstrado que o réu trazia consigo, bem como tinha em depósito, as drogas apreendidas, para fins de tráfico, eis que a expressiva quantidade, a natureza e a diversidade das drogas, além da forma como foram acondicionadas (idênticas em ambas oportunidades em que foram localizadas), somadas à confissão extrajudicial do réu, além dos depoimentos das testemunhas de acusação (policiais militares que realizaram a abordagem e as diligências) comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, do como como narrado na denúncia.

Pelos mesmos motivos acima elencados que comprovam a materialidade e a autoria delitiva, não merece acolhida a pretensão defensiva para que haja desclassificação do crime para aquele descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06, uma vez que para que isso ocorra, é preciso prova segura da exclusividade do porte para consumo próprio o que, no caso, inexistente.

Ressalto que, em um primeiro momento, foram apreendidos com o réu 15 (quinze) invólucros contendo a substância cocaína, localizados dentro de um maço de cigarro e 11 (onze) porções individuais de maconha, localizadas dentro do bolso do réu.

Posteriormente, em sua residência, os agentes localizaram mais 08 (oito) porções de maconha, 85 (oitenta e cinco) invólucros contendo cocaína e 141 (cento e quarenta e uma) porções de crack.

Somadas, a apreensão totalizou em 241 (duzentos e quarenta e um) invólucros de cocaína/crack e 19 (dezenove) porções de maconha ("Auto de Exibição e Apreensão" - fls. 12/13), todas embaladas em porções individuais e prontas para a comercialização, conforme se verifica das fotografias (fls. 19/24), sendo inimaginável que toda essa droga seria para seu uso.

Nota-se, ainda, que o réu informou ser usuário de maconha (fl. 31), no entanto, além desta substância entorpecente, foram encontradas com o acusado tanto em sua posse, quando em depósito em seu quarto, também cocaína e crack, o que reforça o entendimento de que o fato de ser usuário de maconha não afasta a mercância ilegal. Impende consignar que o acusado não demonstrou capacidade financeira para o custeio do alegado vício (a esse respeito, mencionou auferir renda de cerca de R\$ 1.600,00 mensais), não sendo crível que pudesse comprar, para uso próprio e de uma só vez, drogas de diferentes naturezas, em quantidade significativa, também a impedir a desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Observa-se, ainda, que o réu possui passagem por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência (fls. 35/40) e certidão de distribuição criminal (fl. 46), tendo cumprido medidas socioeducativas no ano de 2020 (autos de nº 15001613520208260486), o que indica que não é a primeira vez que realiza o comércio ilícito de drogas.

Assim, ainda que o réu seja usuário de drogas, é evidente que os entorpecentes apreendidos não se destinavam ao próprio consumo, mas ao comércio ilegal, razão pela qual o pedido de desclassificação merece ser rejeitado.

A defesa técnica do acusado sustentou, ainda, que o réu, ao tempo dos fatos, era incapaz, devido ao fato de ser usuário de drogas (dependente químico), sem a capacidade de entendimento e determinação e, por consequência, ausente o dolo, deveria ser absolvido da imputação.

Observo que não ficou demonstrada, durante a instrução processual, a real pertinência da diligência, não tendo sido demonstrado qualquer indicativo que justificasse, por si só, a instauração do incidente (que havia sido indeferida pela

decisão de fls. 182/184, pelo mesmo fundamento, qual seja, a inexistência de elementos aptos a indicar que o réu é dependente químico, a despeito de ter se declarado usuário de maconha).

Noto, também, que em Juízo o acusado se mostrou totalmente sóbrio e respondeu, de forma clara, todas as perguntas que lhe foram formuladas, indicando que tinha total condições de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Acrescento, ainda, que sequer foi apontado pelas testemunhas ou, ainda, pela informante, mãe do acusado, fatos que pudessem indicar a inimputabilidade do réu. Ademais, nenhuma documentação minimamente recente foi apresentada, de forma que indevida a instauração do incidente.

Ressalto que, o fato do acusado ser usuário de droga (no presente caso, maconha), difere do fato de ser dependente químico a ponto de torná-lo incapaz.

Neste sentido, é o seguinte julgado:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Recurso defensivo com pleito preliminar de nulidade, por não instauração de incidente de dependência toxicológica. No mérito, busca redução da pena-base ao mínimo legal. redução da pena de multa, regime prisional mais brando. Preliminar – afastada – Indeferimento do pleito bem fundamentado na r. sentença. Réu que demonstrou higidez mental e intelectual. Não se consignou qualquer anormalidade que conduzisse à necessidade do referido exame. Situação de usuário, que é diversa de dependência química. Condição de usuário que não exclui a de traficante. Mérito – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 456 porções de crack (1,9258 quilos), 729 porções de cocaína (349,5 gramas), 24 quilos de maconha, e 180 frascos de lança perfume (1.548 ml). Prisão em flagrante. Policiais Militares que relataram que avistaram o réu dirigindo o auto Fiat/Marea e este, ao ver a viatura, se evadiu, e na fuga, lançou algo para fora do veículo, sendo detido logo após. Dentro do carro, apreenderam 02 sacos plásticos contendo maconha, e na casa do acusado, apreenderam maconha, cocaína, crack, lança-perfume, balanças de precisão e quantia em dinheiro. Réu que em juízo disse ser dependente químico e admitiu que guardou as drogas em casa em troca de dinheiro. Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor. Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas. Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do patamar mínimo, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida e do registro de maus antecedentes – Na segunda fase, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, sem recurso Ministerial. Na terceira fase, inviabilidade de aplicação do redutor de pena ante o registro de reincidência. Isenção da pena de multa – não cabimento. Regime inicial fechado inalterado. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. (TJ-SP - APR: 15226041220198260228 SP 1522604-12.2019.8.26.0228, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 14/07/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/07/2020). Destaquei.

Assim, não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da acusada ou extingam a sua punibilidade, de modo que a condenação, pela prática de crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe.

Por fim, destaco que o réu não faz jus ao redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006. Isso porque, observo que o acusado possui passagem por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas quando menor, tendo cumprido medida socioeducativa, conforme acima já indicado (cumprida a medida em 02/09/2020 - fl. 225), de forma que, pouco tempo depois, já foi preso em flagrante por tráfico, evidenciam que o acusado vinha se dedicando à atividade criminosa, eis que, após atingir a maioridade, permaneceu em contato com a comercialização de drogas, o que impede a caracterização da causa de diminuição da pena.

Configurado, portanto, o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena do réu em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em estrita observância ao disposto no art. 68 do CP e ao princípio da

individualização da pena.

1ª Fase: No tocante a primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que a culpabilidade do acusado é inerente à espécie. O réu possui bons antecedentes. Não existem elementos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos e as consequências do crime são inerentes a espécie, nada havendo que ser valorado.

Quanto as circunstâncias do delito, em virtude da natureza, grande quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes, a pena deve ser exasperada (nesse sentido, v. STF, HC-94655, entre outros).

Nesse ponto, ressalto que a quantidade de drogas não será considerada nesta fase, vez que já foi utilizada para negar o redutor na terceira fase, a fim de não configurar bis in idem.

Por fim, o comportamento da vítima se não merece qualquer valoração no caso em análise.

Assim, ao final da primeira etapa da dosimetria, deve ser exasperada a pena base em 1/4 por conta da circunstância desfavorável identificada, que deve ser tida como circunstância preponderante (art. 42 da Lei de Drogas), motivo pelo qual fixo ao réu nesta etapa a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, além de 625 dias-multa.

2ª Fase: Na segunda etapa da dosimetria, se faz presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), motivo pelo qual a pena deve ser atenuada em 1/6, restando, ao final desta etapa, a pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa.

3ª Fase: Na terceira e derradeira etapa da dosimetria, não se fazem presentes causas de aumento e tampouco de diminuição da pena.

Nesse ponto, embora pleiteado pela defesa, mostra-se incabível a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Conforme se observa dos autos (fl. 46), bem como pelo próprio réu indicado (fl. 31), pouco tempo antes dos fatos, ele, enquanto menor, já fora condenado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico (autos de nº 15001613520208260486), tendo permanecido internado na Fundação CASA.

Dessa forma, como vem deixando assente o Superior Tribunal de Justiça, a existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, o que entendo presente no caso em tela.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...) 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Destaquei.

Assim, pelas circunstâncias do caso concreto, que indicam a dedicação às atividades criminosas, incabível a aplicação do redutor.

Assim, torno definitiva a pena do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa.

Não havendo informações quanto a efetiva condição financeira do réu, fixo para cada dia-multa o valor mínimo legal, de 1/30 do salário-mínimo (art. 49 do CP).

a) Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e considerando que, embora o réu seja primário, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pela grande quantidade de drogas variadas encontradas, sendo parte delas de natureza nefasta (crack), estabeleço como regime inicial o fechado pelas circunstâncias negativas

apontadas.

Observo que, no caso em tela, o instituto da detração (art. 387, §2º do Código de Processo Penal) não possui o condão de alterar o regime antes fixado.

b) Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena

Considerando a quantidade de pena aplicada, incabível tanto a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP) como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na inicial acusatória, para CONDENAR o réu RICHARD EDUARDO MATIAS DE SOUZA ao cumprimento de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 521 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Incabível tanto a substituição da pena privativa de liberdade quanto a suspensão condicional da pena.

Não havendo informações quanto a efetiva condição financeira do réu, fixo para cada dia-multa o valor mínimo legal, de 1/30 do salário-mínimo (art. 49 do CP).

Considerando que ainda se fazem presentes as situações que justificaram a prisão preventiva do acusado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, já que o acusado mantinha em depósito quantidade considerável de drogas de espécies diversas, e foi preso em flagrante pouco tempo após ter cumprido medida socioeducativa por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, demonstrando que vinha se dedicando à atividade criminosa, deve o réu permanecer preso durante eventual fase recursal. Em caso de recurso, deverá ser expedida guia de execução provisória, encaminhando ao juízo competente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade concedida.

Oportunamente, expeça-se certidão em favor do defensor nomeado, pelo exemplar trabalho realizado ao longo do feito e em suas alegações finais.

Transitada em julgado a presente sentença, inclua-se o réu no rol dos culpados; oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se a respectiva guia de execução definitiva.

P.R.I.

Quata, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA